

1521146-23.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Cesar Muller Valente

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-033, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2127-

9003/04/62, São Paulo-SP - E-mail: sp2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1521146-23.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521146-23.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249427/2020 - 07º D.P. LAPA, 14013232 - 07º D.P. LAPA, 2295/20/307 - 07º D.P. LAPA, 2249427 - 07º D.P. LAPA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lourival Manoel da Silva

Juiz de Direito: Dr. Rodrigo Cesar Muller Valente

Vistos, etc.

Lourival Manoel da Silva, qualificado à fl. 09, foi denunciado como incurso nos artigos 33, caput, e 34, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, e artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porque no dia 7 de outubro de 2020, durante estado de calamidade pública, à tarde, na Rua Bica da Pedra, 106, Perdizes, nesta cidade e Comarca de São Paulo, tinha em depósito, para fins de tráfico, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistentes em 120 porções de cocaína, contendo 95,4g, e 37 porções e 3 tabletes de cannabis sativa l, contendo ao todo 2.260,5g, bem como possuía e guardava instrumento destinado à preparação ou transformação de drogas, também sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ademais, que a prática do réu visava atingir adolescente.

Segundo apurou-se, policiais civis receberam denúncia anônima de tráfico no local acima e para lá se dirigiram, fizeram campana e perceberam a aproximação do menor Felipe Jamil Santiago Nagem, o qual ficou nervoso ao vê-los, ensejando a abordagem. A porta do imóvel estava entreaberta e o réu em seu interior, onde foram encontradas as drogas supracitadas e uma balança de precisão, destinada ao preparo e embalagem das mesmas. O menor, à fl. 15, confirmou que foi ao local comprar drogas e que havia muitos entorpecentes no local. O réu ficou em silêncio. Denúncia recebida em 12 de novembro de 2020, o réu foi citado (fl. 153), e constituiu advogado que apresentou defesa preliminar (fls. 158/159), sendo revogada a prisão em flagrante por excesso de prazo (fls. 134/135), seguindo-se a instrução. Em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A defesa requereu em preliminar a análise conjunta de outro processo em que um adolescente infrator teria confessado a posse das mesmas drogas, de modo a isentar o réu, sustentando ainda que suas restrições físicas o impediriam de realizar a conduta narrada na denúncia, para postular absolvição por falta de provas.

Este é o relatório.

Passo a decidir.

O requerimento preliminar de prova acrescida deixou de ser formulado no momento processual oportuno, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, operando-se preclusão, sendo, ademais, de todo descabido, conforme adiante exposto.

A ação penal é parcialmente procedente, afastado o concurso material de tráfico de drogas com o crime tipificado no artigo 34 da mesma lei.

Auto exibição e apreensão de fl. 16 e auto de constatação prévia de fls. 22/25 indicam 120 porções de cocaína, contendo 95,4g, e 37 porções e 3 tabletes de cannabis sativa l, contendo ao todo 2.260,5g, e uma balança pequena de precisão na cor cinza.

Laudo de exame químico-toxicológico de fls. 105/107 indica resultados positivos para tetrahydrocannabinol e cocaína nas respectivas amostras.

Está provada a materialidade delitiva, tal como consta na denúncia.

Em fase inquisitiva, o adolescente Felipe Jamil Santiago Nagem informou que é usuário de entorpecentes há cerca de seis anos e que, na data dos fatos, foi até a casa da Rua Bica de Pedra, nº 106, para comprar entorpecentes. Quando estava na porta, foi abordado pela equipe de policiais, que entraram no imóvel, o qual estava com a porta entreaberta, e lá encontraram muitos entorpecentes.

Os policiais civis Cesar Rodrigues Alves do Nascimento e Eduardo Roberto Martins relataram que receberam informações de que no local dos fatos estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes, onde uma pessoa do sexo masculino e gorda, vendia e guardava entorpecentes no interior do imóvel daquele local. Diante destas informações, se dirigiram ao local e lá, após verificarem que uma pessoa, ora o adolescente Felipe Jamil Santiago Nagem, que figura como testemunha, estava em atitude suspeita e diante do nervosismo que o adolescente apresentava, decidiram pela abordagem. Em seguida adentrou na residência, que tinha sua porta entreaberta e dentro do imóvel depararam-se com o réu, que mantinha sob sua guarda grande quantidade de drogas, prontas para venda. Localizaram 120 papéletes de cocaína e 37 trouxinhas de maconha que se encontravam prontas para a venda e consumo, além de 3 tabletes da mesma droga embaladas também pronta para a venda, totalizando dois quilos e trezentas gramas. Assim, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao réu e, juntamente com as drogas, uma balança de precisão e o adolescente que serviu como testemunha, foram apresentados na Delegacia de Polícia.

O réu, na fase extrajudicial, permaneceu em silêncio.

Em audiência de instrução:

Cesar Rodrigues Alves do Nascimento, policial civil, relatou que averiguava informação sobre tráfico de drogas em determinada residência, a primeira ao lado de uma escadaria, onde alguém com apelido "Tim" estaria comercializando drogas; chegando lá, encontrou o réu fumando entorpecente, e ao lado dele uma mochila com grande quantidade de maconha, e um possível comprador estava junto com o réu, "o réu estava sentado numa poltrona terapêutica, o outro estava de pé, os dois no mesmo quatinho, e o outro disse que estava ali para comprar drogas e trazia apenas

uma mochila de trabalho, não se recordando se o outro era adolescente ou se trazia drogas. Não se recorda o que o réu afirmou ao ser abordado. Encontrou no local, além tablete e porções de maconha, uma balança, tudo dentro da mochila do réu. Na mesma mochila do réu também havia cocaína. Não se recorda sobre apreensão de dinheiro. Identificou o réu e confirmou que ele tem problema de locomoção. Às perguntas da defesa, respondeu que existem mais de cinco casas no mesmo terreno. O réu reside na casa, onde ingressaram primeiro, de onde a esposa dele apontou o cômodo onde ele se encontrava. A esposa do réu anunciou que não havia nada de ilícito na casa e que poderiam vistoriar o local, sendo feita apenas vistoria superficial. O réu foi abordado num quarto externo, sem porta, acessível pelo mesmo quintal onde existem mais de cinco casas. Naquele cômodo, recorda-se apenas da poltrona fixa de massagem.

Eduardo Roberto Martins, polícia civil, reportou-se à prévia informação sobre prática de tráfico de entorpecentes no local dos fatos, quando então, e em breve campanha, observou várias casas no mesmo terreno, com pessoas entrando e saindo por uma escadaria, e subiram atrás de uma daquelas pessoas, um adolescente, que ingressou num cômodo, "tipo um quarto", dentro do qual o réu foi surpreendido, e naquele mesmo cômodo havia uma mesa com entorpecentes a vista, "em cima da mesa e um pouco no chão, tudo a vista, tinha maior quantidade de maconha em tijolo, vários saquinhos de cocaína e maconha já embalada", aparentemente ele manipulava e embalava entorpecentes naquele local, e ao ser abordado o réu nada declarou; o réu residia num cômodo mais abaixo, no mesmo terreno, e as drogas estavam numa espécie de edícula; havia ainda balança de precisão e papel para embalagens; o adolescente afirmou que pretendia comprar drogas; não conhecia o réu; a operação foi motivada por "denúncia anônima" referente ao local e características do suspeito, "pessoa de idade e obeso". Identificou o réu em audiência.

Interrogado ao final da instrução, o réu Lourival Manoel da Silva negou a prática delitiva, dizendo que "não foi pego nada comigo, passaram uns caras correndo, não foi pego nada dentro da minha casa, eu estava lá fazendo terapia, na casa debaixo, uma casa sem porta, onde tem lugar de fazer terapia".

Portanto, diversamente do que sustentou a defesa em alegações finais, de modo algum o adolescente presente no local da apreensão das drogas pretendeu isentar o réu, pelo contrário, foi categórico ao incriminá-lo, formalizando-se tal versão na lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo irrelevante apurar o que declarou o adolescente em oitiva informal perante o Ministério Público ou ainda nas audiências de apresentação e de instrução realizadas na Vara da Infância e Juventude, eis que aqueles suas declarações naqueles autos são válidas tão-somente para apuração de ato infracional, e não elidem o auto de prisão em flagrante para efeitos dos artigos 60 e 155 do Código de Processo Penal.

Do que resta, as testemunhas policiais afastaram completamente a possibilidade daquele cômodo servir de espaço para que o réu realizasse exercícios, pois, de modo uníssono, reiteraram suas primeiras declarações, no sentido de que havia drogas dispostas sobre a mesa, a vista de todos, e também espalhadas pelo chão, evidenciando-se que aquele espaço era destinado exclusivamente para traficância.

Baseando-se em tais provas, sobre a validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante, devem ser acolhidos como elementos de prova, eis que uníssonos e coerentes com o teor do auto de prisão em flagrante, prevalecendo a presunção de legalidade e veracidade de que se revestem os atos dos agentes públicos, constituindo ônus da defesa a prova em sentido contrário, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, e nesta ação penal não se tem qualquer indício de suspeição ou ilegalidade que possa macular o valor de tais depoimentos. Reporto-me ao entendimento jurisprudencial:

PROVA CRIMINAL - Testemunha - Tráfico de tóxico - Depoimento prestado por policial - Validade - Inexistência de razão concreta para a suspeição - Relato firme e coerente - Apreensão da droga, ademais, presenciada por testemunha alheia aos quadros da polícia - Recurso não provido - JTJ 241/313.

CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA - Prova criminal - Depoimento de policial participante de diligência do flagrante - Testemunho coerente e seguro - Validade - RT 595/423.

E quanto ao elemento subjetivo do crime atribuído ao réu, inequivocamente manter em depósito centenas de porções de drogas variadas caracteriza prova de mercancia ilícita, mesmo porque, o próprio réu afastou a possibilidade da droga destinar-se a consumo pessoal.

Por fim, não cabe arguir nulidade do flagrante por preparação ou falta de ordem judicial para permanência dos policiais na residência do réu, na medida em que as provas colhidas no curso da ação penal revelam que não houve instigação, participação ou colaboração dos policiais na posse e comercialização de drogas pelos acusados, tratando-se de crime de natureza permanente, que se consumou desde antes da atuação policial. Nesse sentido: "PRISÃO - Flagrante preparado - Tráfico de tóxico - Compra do produto simulada por policial - Irrelevância - Crime de natureza permanente - Delito já caracterizado antes da simulação - Crime impossível não configurado - Recurso provido" - JTJ 209/284. "PRISÃO - Flagrante preparado - Inocorrência - Tráfico de entorpecente - Crime de natureza permanente - Consumação do delito que preexistiu ao flagrante - Recurso não provido" - JTJ 208/273.

Quanto à arguição defensiva, no sentido de que a polícia invadiu a residência do réu sem autorização, fica afastada, porque, conforme relataram os policiais o flagrante de tráfico ocorreu num cômodo separado, uma espécie de edícula situada em terreno comum de várias residências, dentre as quais a residência do réu, local diverso da apreensão. Aplicando-se ao fato reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, a guarda de entorpecente é delito permanente sendo possível a prisão em flagrante enquanto não cessar a permanência (STF - RHC 53.659), circunstância que afasta qualquer ilicitude a macular a prova produzida: "Violação de domicílio - Inocorrência - Ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência, em que se realizava comércio ilícito de entorpecente - Garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio que é inaplicável nos casos de flagrante delito - Inteligência do art. 5º, XI da Constituição Federal. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio cede espaço nos casos de flagrante delito (CF, art. 5º, XI), não merecendo censura a ação policial intentada com o objetivo de efetuar prisão no interior de residência em que se realizava comércio ilícito de entorpecente, em especial quando a entrada ocorreu sem arrombamento." (RT 771/565).

Por outro lado, merece ressalva a pretensão acusatória, quanto à caracterização do crime do artigo 34 da Lei 11343/06.

A mera posse do item descrito em auto de exibição e apreensão como "uma balança pequena de precisão na cor cinza", não necessariamente implica reconhecer que o réu praticasse, de modo autônomo e com dolo específico, quaisquer das modalidades típicas capituladas naquele tipo penal, visando especificamente "maquinário, aparelho, instrumento ou qualquer objeto destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de drogas". Tudo leva a crer que o traficante dispunha de uma pequena balança para rápida separação e individualização das porções de drogas, simultaneamente às vendas. Admitir-se o contrário, conforme postulado pelo Ministério Público, seria condenar com base em mera presunção.

Nesse sentido, o jurista Heleno Cláudio Fragoso (Jurisprudência Criminal, Editora Forense, 4ª edição, página 506), observava: "Não é possível fundamentar sentença condenatória que não conduza à certeza. Esse é um dos princípios basilares do processo penal em todos os países democráticos. A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno da existência de certa realidade".

Acerca dessa matéria: "PROVA. Insuficiência para condenação. Exame dos elementos probatórios obtidos em inquérito policial que não leva à desejada e imprescindível segurança capaz de amparar juízo condenatório. Absolvição decretada. Aplicação do art. 386, VI, do CPP" (TJSP - RT 666/274). No mesmo sentido: "Simples indícios por mais veementes que sejam, não bastam, por si só para justificar conclusão de culpabilidade" (Apelação 153.211, TACRIM-SP). "O Direito Penal não opera em conjecturas. Sem a certeza total da autoria e da culpabilidade não pode o juiz criminal proferir condenação" (Apelação 170.407, TACRIM-SP)."

Procedente em parte a ação penal, afastado o crime do artigo 34 da Lei 11343/06.

Passo ao cálculo das penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal, e do artigo 42

da Lei 11343/06.

Sobre a pena base, para o crime de tráfico, cabe considerar a quantidade e variedade de drogas apreendidas, com potencial de dano difuso à saúde pública devido ao grande número de usuários faz incidir a regra do artigo 42 da Lei nº 11.343, impondo-se acréscimo de pena de 1/5, em seis anos de reclusão e seiscentos dias multa. O réu é reincidente específico (22ª Vara Criminal da Capital - 0007479-41.1993.8.26.0050), devendo ser acrescida a pena nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, em 1/6, somando sete anos de reclusão e setecentos dias multa.

Presente circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea J, do Código Penal, prevê circunstância objetiva da conduta, consistente em praticar crime em "qualquer calamidade pública", isto é, quem praticar crime em tal circunstância, independentemente de sua intensão, receberá tratamento legal diferenciado. O Decreto número 64879, de 20 de março de 2020, que reconheceu o estado de calamidade pública no Estado de São Paulo decorrente da pandemia do Covid-19, foi largamente divulgado por todos meios de comunicação, de conhecimento, sendo inviável alegar ignorância da situação atual de pandemia. Inequivoco, portanto, que a conduta de praticar tráfico de drogas durante a situação de calamidade pública representa risco ainda maior à saúde pública, pois, não atenta apenas contra a saúde daquele que consome a droga objeto material do crime de tráfico, mas, primordialmente, promove aglomeração de pessoas no local da prática do crime de tráfico, concorrendo para disseminação da doença e contágio coletivo, risco que o traficante assumiu e será apenado proporcionalmente à gravidade da conduta criminosa. Aplica-se, portanto, acréscimo de pena de 1/6, em oito anos e dois meses de reclusão e oitocentos e dez dias multa. Na terceira fase da dosimetria, presente a causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, porque o réu venderia drogas para adolescente no momento em que foi preso em flagrante, devendo ser acrescida a pena de 1/6, totalizando nove anos, seis meses e dez dias de reclusão, e novecentos e quarenta dias multa. A reincidência afasta, por expressa disposição legal, a causa especial de redução de pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33, benefício legal de caráter excepcional, adstrito a traficantes primários e desde que plenamente favoráveis as circunstâncias judiciais, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, e o tempo de prisão descontado no curso do processo entre o flagrante e a soltura provisória por excesso de prazo não é suficiente para antecipação de regime prisional menos gravoso com fundamento no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal.

Os dias multa serão calculados em valor unitário mínimo legal, não havendo prova de condição econômica do réu, conforme preceitua o artigo 60 do Código Penal.

Do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal, para condenar o réu Lourival Manoel da Silva, qualificado à fl. 09, como incurso nos artigos 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, cc. artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, às penas de nove anos, seis meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e novecentos e quarenta dias multa, calculados em valor unitário mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de cem ufesp (artigo 4º, § 9º, "a", Lei Estadual 11.608/2003).

Ao trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à Justiça Eleitoral nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal.

A prisão cautelar foi revogada por excesso de prazo, não tendo sido o réu beneficiado com ordem de habeas corpus no curso da instrução. Prevalece sobre a regra geral do artigo 311 do Código de Processo Penal, a regra da Lei Especial, em seu artigo 59 da Lei 11343/06: "o réu não poderá apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for primário e de bons antecedentes". Fica indeferida a possibilidade de recorrerem em liberdade. Súmula nº 9 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que:

"A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência". Se o criminoso respondeu preso ao processo, deve permanecer na mesma situação, sob pena de contrassenso, eis que a prisão decorrente de sentença condenatória recorrível, assim como as demais formas

de prisão cautelar, não representam "pena antecipada", mas, sim, decisão de natureza cautelar sobre periculosidade do criminoso, servindo para resguardar a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, razão por que não se há de cogitar de violação do princípio constitucional da presunção de inocência. Expeça-se mandado de prisão. Oportunamente, expeça-se guia de execução.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de setembro de 2022.

Rodrigo César Müller Valente
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA